

1500086-50.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO NUNES DE ASSIS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ADRIANO NUNES DE ASSIS, qualificado no inquérito, foi denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500086-50.2022.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-50.2022.8.26.0510 - 2022/000026

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO NUNES DE ASSIS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ADRIANO NUNES DE ASSIS, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 11 de janeiro de 2.022, por volta das 09:51 horas, na Avenida 58,

com a Rua 17, Parque Universitário, neste município e Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 28 (vinte e oito) invólucros com a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de mesclado, e ainda guardava e tinha em depósito outros 04 (quatro) invólucros com a mesma substância entorpecente, na forma de mesclado, totalizando com aqueles outros peso líquido aproximado de 28,89 gramas, 15 (quinze) microtubos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 3,85 gramas, e 13 (treze) invólucros com a mesma substância entorpecente, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 4,08 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de constatação de fls. 23/25, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 15 de julho de 2022.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena base no mínimo legal, devendo ainda ser agravada por conta da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com cumprimento da pena cominada em regime prisional inicial fechado. Já a ilustre Defensora Pública, preliminarmente, sustentou assentada a materialidade do delito em prova ilícita, decorrente a apreensão do entorpecente de busca pessoal realizada em afronta ao que disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a determinar a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, do Código de Processo Penal. No mérito, entendendo insuficiente a prova produzida, pugnou também pela absolvição, aqui nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de acolhimento da pretensão acusatória, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão, de modo a compensá-la com a recidiva, possibilitando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que nova consideração da recidiva nesta fase importaria em bis in idem, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 28 (vinte e oito) invólucros com a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de mesclado, e ainda guardava e tinha em depósito outros 04 (quatro) invólucros com a mesma substância entorpecente, também na forma de mesclado, totalizando peso líquido aproximado de 28,89 gramas, além de 15 (quinze) microtubos do tipo eppendorf contendo 3,85 gramas de cocaína, e 13 (treze) invólucros com 4,08 gramas da mesma substância entorpecente, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, e laudo de constatação de fls. 23/25 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 80/81, com resultado positivo para cocaína.

Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida, por derivação, já que decorrente a apreensão de busca pessoal ilícita, inexistindo fundada suspeita a autorizá-la, em afronta ao que disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, como se extrai da prova produzida, o Acusado se encontrava parado em local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e se encontrava agachado junto a um poste de iluminação, tendo empreendido fuga quando da aproximação de

Policiais Militares, seguindo-se a abordagem e a busca pessoal.

Deste modo, estando o acusado em local de ponto de venda de entorpecente, agachado junto a um poste e tendo procurado encetar fuga quando da aproximação de Policiais Militares, constitui, tendo os olhos postos na realidade, além da consideração do tirocínio policial, fundada suspeita de que estava realizando o comércio ilícito, e isto se mostra tanto mais verdadeiro, que resultou efetivamente na apreensão de várias porções de cocaína, mesclado e crack.

Assim, respeitada a objeção deduzida, diante dos elementos concretamente considerados, não se entende ilícita a busca pessoal realizada, a comprometer, por derivação, a materialidade do delito.

Também não socorre ao acusado a invocação da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, assim porque afirmou que cuidava apenas em vender o entorpecente, porque receberia algumas porções para o próprio uso. À evidência que não era inexigível conduta diversa, porque outros recursos existiriam para a obtenção de entorpecente, da forma como anteriormente aos fatos o Acusado atendia à sua condição de usuário.

E a autoria foi suficientemente evidenciada.

Ouvido em Juízo, o Acusado afirmou que era, na ocasião dos fatos, morador de rua e que mantinha e venderia o entorpecente apreendido para um indivíduo que se identificou como "Du", recebendo pela atividade algumas pedras de crack, sendo usuário.

A não se dizer isolada, a confissão externada pelo Acusado foi amparada pela prova oral e pericial produzidas.

De fato, a Policial Militar Julia Vargas, reiterando em Juízo o que exposto anteriormente, afirmou que estavam em patrulhamento em conhecido ponto de venda de entorpecente quando avistaram o Acusado agachado junto a um poste, tendo tentado empreender fuga quando notou a aproximação da guarnição, por isto que foi em seguida abordado, seguindo-se a apreensão com ele de algumas porções de entorpecente. No local onde inicialmente avistado, foram apreendidas outras porções da mesma substância entorpecente, composta de crack, mesclado e cocaína, tendo o Acusado admitido que estava realizando o comércio ilícito do entorpecente apreendido, pertencente a terceiro, assim porque receberia algumas porções que estariam destinadas ao próprio uso (fls. 133).

Neste mesmo sentido o Policial Militar Wilson Carlos (fls. 133).

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Deste modo, para além da confissão externada do Acusado, os Policiais Militares confirmaram a apreensão do entorpecente em poder do Acusado, revelando ele a realização do comércio ilícito, a possibilitar seguro juízo de convicção sobre a realidade da imputação inicial, com incontornável acolhimento da pretensão acusatória.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, embora de naturezas diversas, possível seja a pena base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância agravante da reincidência (fls. 27), entendendo preponderar a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a consideração também neste momento da recidiva, notadamente a específica, também se afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da

Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, 65, inciso III, alínea "d" e 67, todos do Código Penal, CONDENO o acusado ADRIANO NUNES DE ASSIS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser considerada a recidiva e também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria devotos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênua, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de

flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art. 59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído apenas privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA